

1006188-06.2021.8.26.0309

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Marcio Estevan Fernandes

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... com tutela antecipada e dano moral. Furto do magnético. BO. Operações de saque. Súmula 479 do STJ. Fraude. Sentença de procedência declarando inexigível a obrigação e fixando dano moral a soma de R\$ 8.000,00. 2. Apelação (Banco). Relação de consumo. Fraude. Cerceamento inocorrente. Segurança máxima do sistema não comprovada. Boletim de ocorrência. Presunção de boa-fé. Existência de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP

Foro de Jundiaí

4ª Vara Cível

Largo São Bento, s/nº, Jundiaí - SP - cep 13201-035

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1006188-06.2021.8.26.0309 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1006188-06.2021.8.26.0309

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Ivan Gimenes Machado

Requerido:

Banco Bradesco S/A e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcio Estevan Fernandes

Vistos.

IVAN GIMENES MACHADO move "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c RESSARCIMENTO DE VALORES e PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" contra BANCO BRADESCO S.A. e BANCO NEXT S/A. Afirma que tomou conhecimento de que seu nome havia sido incluído nos cadastros de SCPC/SERASA pela parte ré em virtude de débitos que lhe foram atribuídos, no valor de R\$ 1.745,83 (mil setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos), doc. de origem nº 347886888000024 e no valor de R\$ 9.178,43 (nove mil cento e setenta e oito reais e quarenta e três centavos), tendo como natureza da operação "cartão de crédito", contrato nº 347886888000024 e descrição do produto nº **** * 4206. Ajuíza a presente demanda objetivando a declaração de inexistência do débito com a consequente baixa das restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito e condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 10.000,00.

O pedido de antecipação foi deferido (fl. 31).

Citados, BANCO BRADESCO S.A. e BANCO NEXT S/A sustentam que as operações exigem senha e token, além de chave de segurança intransferível. Requerem a improcedência dos pedidos. (fls. 40/51)

Anote-se réplica. (fls. 106/111)

Vencido o elastério, as partes ofertaram memoriais (fls. 196/208).

É o relatório.

Decido:

Em favor do autor, porque consumidor, aplica-se a inversão do ônus da prova, em razão, outrossim, da verossimilhança de suas alegações.

No entanto, nem disso se cogitaria na espécie.

É que os bancos, ao contestaram o pedido sob alegação de regular contratação, atraíram para si o ônus de demonstrar que o negócio jurídico objurgado teria decorrido de análise da documentação do autor, como documentos de identidade, comprovante de residência e outros correlatos.

Bem por isso, concedeu-se aos bancos a oportunidade de realizar tal prova.

E, ao responderem à intimação, trouxeram de fato os bancos a documentação de que dispunham, oportunidade a partir da qual passaram a defender a ocorrência de fraude e responsabilidade de terceiro, assim como a inexistência de dano moral, correspondendo os fatos a meros aborrecimentos.

Evidente que a tese defendida na resposta, de regularidade da contratação, caiu por terra porque os bancos, atentando-se agora para a documentação que dera respaldo ao negócio, convenceu-se de que o autor foi vítima de fraude.

No mais, o autor é consumidor e os fatos por ele alegados são verossímeis, de modo que não cabe exigir dele qualquer prova, senão dos réus, a respeito de como se deram os fatos. Estes, a tanto instados, reconheceram a fraude.

De todo modo, ao contrário do que sustentara a parte ré, a jurisprudência não tem por invulnerável a utilização do "sistema CHIP", com ou sem "Token", também sujeito a vicissitudes decorrentes da astúcia de certos larápios.

A propósito, já se decidiu:

BANCÁRIOS - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos materiais e morais - Parcial procedência - Operações de TED's não reconhecidas - Hipótese em que a instituição financeira afirma que a operação foi efetuada com o uso de senha pessoal e Token fornecidos pela cliente a fraudadores - Banco que não apresentou provas dessa alegação, e nem impugnou as alegações da cliente - Ônus que lhe cabia (art. 373, II, e 374, III, do CPC/2015) - Prestação de serviço defeituoso ou fortuito interno, caracterizados - Responsabilidade objetiva da instituição financeira ante o risco da atividade (Súmula 479 do STJ) - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11). (TJSP; Apelação Cível 1003976-24.2019.8.26.0554; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 03/02/2020)

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Realização de saques indevidos na conta corrente da autora. Alegação de que as operações se deram através de

cartão com chip mediante uso de senha pessoal que não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade do banco. Falha na prestação de serviços. Caracterização Indenização devida. Tendo havido a realização de saque indevidos da conta de correntista do banco, ocasionado por falhas relativas à prestação de seus serviços, deve este responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao seu cliente. Quantum indenizatório fixado em R\$ 5.000,00, a título de danos morais Recurso provido." (TJSP - Apelação nº 0028003-73.2011.8.26.0003)

"Responsabilidade civil. Saque indevido. Tese sustentada na inicial verossímil, considerando versar a ação sobre consumo e ser o autor hipossuficiente. Não pairou dúvida de que os saques realizados na conta poupança de titularidade do autor foram indevidos. Sistema de segurança dos cartões magnéticos que é vulnerável a fraudes. Tese de que somente é possível efetuar-se retirada com a utilização de cartão magnético e aporte de senha pessoal ilusória. Existência de notícia de que até mesmo os cartões magnéticos munidos com "chip" de segurança já foram clonados. Responsabilidade civil. Saque indevido. Admitida a possibilidade de violação do sistema em questão, havendo operações, quer de compras, quer de saques, não reconhecidas pelo cliente, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço. Responsabilidade apenas passível de ser refutada nas hipóteses do § 3º do art. 14 do CDC. Circunstância em que, no caso vertente, nenhuma dessas situações de exclusão de responsabilidade verificou-se [...]"(TJ/SP, Apelação 0002779-86.2010.8.26.0127, rel. Des. José Marcos Marrone, julgada em 08/04/2015).

"1. Ação declaratória negativa cumulada com tutela antecipada e dano moral. Furto do magnético. BO. Operações de saque. Súmula 479 do STJ. Fraude. Sentença de procedência declarando inexigível a obrigação e fixando dano moral a soma de R\$ 8.000,00. 2. Apelação (Banco). Relação de consumo. Fraude. Cerceamento inocorrente. Segurança máxima do sistema não comprovada. Boletim de ocorrência. Presunção de boa-fé. Existência de chip que não torna a operação isenta de falhas ou equívocos. Ônus da prova. Perfil do cliente [...]"(TJ/SP, Apelação 0181871-71.2011.8.26.0100, rel. Des. Carlos Abrão, julgada em 15/04/2015).

Observa-se, no entanto, já se antevendo nova demonstração de culpa dos réus, que as transações questionadas fogem, completamente, do perfil comum do autor.

Relativamente ao dano moral, tenho que os fatos de que foi vítima o autor amparam sua pretensão, sobretudo a inércia dos bancos em solver a questão, colocando-se verdadeiramente como adversário do cliente e jamais como um aliado.

Nem mesmo quando constituiu advogado ou após o ingresso da ação teve voz o autor, cingindo-se, depois de negar a fraude e em seguida admiti-la, que o autor não padeceu de dano na órbita moral.

A propósito:

Apelação. Indenizatória. Saques e empréstimos indevidos. Improcedência. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Risco da atividade. Súmula nº 479 do C. STJ. Ônus probatório quanto à regularidade das operações realizadas que compete ao banco. Cartão bancário com "chip". Irrelevância. Possibilidade de fraude notória. Ausência de sistema de identificação biométrica, o que demonstra a fragilidade da segurança oferecida à cliente. Movimentações que refugiram, por completo, ao perfil da consumidora. Inexistência dos débitos declarada, com a determinação de devolução dos valores indevidamente debitados e sacados da conta corrente da autora. Danos morais configurados. Arbitramento em R\$ 10.000,00, atendidos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1008229-65.2018.8.26.0077; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/02/2022; Data de Registro:

03/02/2022)

AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-COMMERCE - MERCADO LIVRE - CLARO S/A - SAQUE FRAUDULENTO DE QUANTIA PROVENIENTE DE VENDAS - Responsabilidade objetiva e solidária das prestadoras de serviços de telefonia e de "e-commerce" - Fraude com troca de chip da linha do celular do autor cadastrada na plataforma do e-commerce que possibilitou o acesso de terceiros à conta do autor na plataforma Mercado Livre - Movimentação fraudulenta da conta - Prestação do serviço defeituoso configurada - Repetição de indébito de forma simples do valor contestado - Cabimento - Fatos e circunstâncias autorizadoras do pleito indenizatório por ofensa moral - Dano "in re ipsa" - Indenização ora fixada em R\$ 10.000,00 - Sentença reformada. Recurso do autor provido. Recurso da corré parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1000160-25.2019.8.26.0072; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Viradouro - Vara Única; Data do Julgamento: 21/10/2021; Data de Registro: 22/10/2021)

No caso dos autos, em decorrência do descaso dos réus, o nome do autor foi incluído em cadastros restritivos de crédito, e somente retirado, mesmo com a discordância dos réus, por decisão judicial.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido e declaro extinto o processo, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando o encerramento das contas e cartões vinculados ao CPF do autor, confirmando a medida concessiva de antecipação de tutela. CONDENO os réus ao pagamento em favor do autor, a título de compensação de dano moral, o valor de R\$ 10.000,00, a ser atualizado a partir da publicação desta sentença. A atualização do valor dar-se-á pela Tabela Prática do E. TJSP. Os juros, de 1% ao mês, incidirão do evento danoso (ilícito extracontratual). Condeno o réu, por fim, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados estes em 20% sobre o valor da causa (valor da causa compreende o valor declarado inexigível e o quantum relativo à compensação de dano moral).

P.R.I.C.

Jundiaí, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA